

1500165-21.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... que pudesse ensejar seu envolvimento no tráfico de drogas. Também inexitem nos autos quaisquer informações seguras de que ele seria traficante. Sequer havia denúncia anônima indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Não havendo denúncia anônima concreta, apreensão de dinheiro ou qualquer outro objeto relacionado ao tráfico, como ainda, não sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500165-21.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038123/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 22923906 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2038123 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

JOVAIR APARECIDO ROQUE foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 09 de fevereiro de 2022, na rua Júlio Bonucci Filho, nº 10, Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca, nas proximidades de uma entidade religiosa, trazia consigo para consumo de terceiros, 36 papелotes de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

LUIS ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque no dia 09 de fevereiro de 2022, na rua Júlio Bonucci Filho, nº 10, Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca, nas proximidades de uma entidade religiosa, trazia consigo para consumo de terceiros, 11 papелotes de cocaína, 14 pinos de cocaína e uma bucha de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificados, os acusados apresentaram defesa preliminar às fls. 136/138 e 175/176. Recebida a denúncia aos 11 de abril de 2022 (fl. 178), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fl. 233).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia e do seu aditamento, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 237/244).

A defesa de Luis postulou, preliminarmente, a nulidade ab initio do procedimento, embasada na ilicitude da abordagem policial. No mérito, pugnou pela descCLASSIFICAÇÃO para o crime previsto no artigo 28 da lei de drogas (fls. 261/272). A defesa de Jovair requereu sua absolvição embasada na ausência de provas da autoria e na fragilidade dos depoimentos colhidos, além de combater a causa de aumento de pena denunciada (fls. 275/287).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, a preliminar trazida pela defesa de Luis está absolutamente interligada ao mérito da demanda, motivo pelo qual será com ele analisada.

No mérito, a materialidade de delito contra a saúde pública está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 141/155) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são maconha e cocaína, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos, a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas imputado a Luis não restou devidamente comprovada.

Em seu interrogatório, assim como fizera na etapa policial, ele admitiu a propriedade da droga apreendida consigo (18 pinos de cocaína), argumentando que a destinaria ao seu consumo pessoal.

Esclareceu que naquele dia conduzia seu veículo pelo local dos fatos, na companhia de sua namorada, seguindo em direção a sua residência. Em determinado momento foi abordado por policiais militares. Durante revista, eles apreenderam no interior do seu veículo as porções de cocaína. Por fim, declarou que o coacusado Jovair já se encontrava detido pelos policiais quando eles promoveram a sua abordagem.

Por outro lado, os agentes que apreenderam a droga relataram que, enquanto realizavam a abordagem policial do coacusado Jovair naquele dia, visualizaram um veículo Gol, conduzido por Luis, trafegando pelo local. Explicaram que ele também foi abordado e em seu veículo localizadas porções de cocaína.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado a Luis. Senão vejamos.

Não obstante a abordagem policial aos acusados tenha sido realizada na mesma

ocasião, não se comprovou o vínculo ou liame entre eles, tudo indicando que foram realizadas abordagens contínuas, sem qualquer ligação entre os agentes. Não obstante, ambos acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e autuados em flagrante pela prática de tráfico de drogas.

Saliente-se, ainda, que muito embora na exordial o órgão acusatório tenha narrado que teriam sido apreendidos em poder de Luiz onze papelotes de cocaína e quatorze pinos da mesma droga, além do entorpecente existente com Jovair (36 papelotes de cocaína e duas buchas de maconha), o fato é que, em que pese à ausência de vínculo entre os acusados, foram os acontecimentos noticiados numa única ocorrência policial (um único boletim de ocorrência e um auto de prisão).

Tal fator leva-nos à dúvida da quantidade exata em que cada um dos acusados possuía consigo no momento de suas abordagens. Isso porque não se pode descartar que ao serem conduzidos conjuntamente à Delegacia, os policiais possam ter se equivocado quanto à quantidade trazida por eles.

A par disto, observa-se pelos depoimentos dos policiais que eles não especificaram quanto cada um dos acusados portava de drogas, narrando de forma genérica a apreensão do entorpecente durante a diligência policial. Anote-se que, enquanto o PM Junio disse que no veículo dirigido por Luis teria havido apreensão de mais cocaína, o PM Erick declarou que no veículo havia mais entorpecente.

Repise-se, que tanto na etapa policial, assim como em Juízo, Luis argumentou que em seu veículo apenas havia 18 pinos de cocaína, destinados ao seu consumo pessoal. Lado outro, ele declarou que no momento em que foi abordado pelos agentes públicos rumava em direção a sua casa. De fato, observa-se que o local da abordagem policial, noticiado no documento de ocorrência de fl. 17, é a rua Júlio Bonucci Filho, nº 10, Jardim Morumbi. Acrescente-se que o acusado admitiu residir à rua Júlio Bonucci Filho, nº 76, Jardim Morumbi. Portanto, ele foi abordado na rua em que mora.

Analisando tais fatos, a par dos depoimentos colhidos, fica evidente a ausência de provas que demonstrem que a droga apreendida em poder de Luis estaria destinada ao tráfico ilícito. Se não bastasse, os agentes públicos não presenciaram nenhuma conduta do acusado que demonstrasse que ele estaria no local realizando o tráfico de drogas.

Desta forma, as circunstâncias da diligência e da apreensão, revelaram insegurança na prova e retiraram a credibilidade da versão denunciada, necessária para uma condenação por tráfico de drogas.

As vãs tentativas dos policiais em afirmar que Luis é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico de drogas não são suficientes para embasar uma condenação. A palavra dos agentes públicos, embora seja aceita cotidianamente pelo Juízo como prova apta a sustentar uma condenação, deve vir cercada de elementos que a assegurem e isenta de contradições.

Destarte, tal entendimento, porém, não afasta a necessidade de exame do restante da prova, cotejando a versão dos policiais com o restante do contexto probatório. Assim, apenas quando coerente com o restante da prova dos autos é que poderão os depoimentos dos agentes públicos embasar uma decisão condenatória.

Daí a imprescindibilidade de serem, sempre que possível, identificadas e inquiridas testemunhas presenciais do fato ou da abordagem policial, de modo a permitir o esclarecimento das circunstâncias do caso concreto de forma mais segura e detalhada.

O esclarecimento do fato, aliás, é a finalidade propriamente dita da atividade policial. Segundo dispõe o artigo 6º do Código de Processo Penal, a autoridade policial deve, assim que tiver conhecimento da prática da infração, "colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias".

Não obstante isto, se tem observado em inúmeros processos, notadamente aqueles envolvendo imputações por tráfico de drogas, a absoluta ausência de testemunhas da abordagem policial ou do flagrante.

Sendo possível o acompanhamento da diligência por uma pessoa fora dos quadros, como aconteceu na espécie, já que a diligência policial ocorreu no período da tarde, por volta de 13 horas, num local movimentado, não se pode aceitar como absoluta as

palavras dos policiais militares.

Não se trata, à evidência, de questionar ou duvidar dos seus depoimentos que, no cumprimento de suas missões, atuam na repressão penal, posto que tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Trata-se, isso sim, de exigir a correta formação de culpa em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado. Nessa esteira, verifica-se que a prova não trouxe a tranquilidade necessária e indispensável para fundamentar o decreto condenatório.

De todos os relatos ouvidos em juízo não se pôde obter certeza de que Luis tenha, de fato, praticado o delito a ele imputado (tráfico de drogas).

Portanto, nota-se que não há provas suficientes de que o acusado seja o autor do delito a ele imputado, pois os elementos de convicção trazidos não se mostraram seguros e coerentes o suficiente para, de forma isolada, fundamentar o édito condenatório.

Frise-se que um dos princípios basilares do processo penal é a busca da verdade real. Havendo dúvidas sobre a existência do crime, tais incertezas devem ser resolvidas em benefício do acusado, aplicando-se, in concreto, o princípio do in dubio pro reo, no que tange ao delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

"A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ Ministro Marco Aurélio Bellizze 5ª Turma ArRg no AREsp n.631/MG DJe 03/09/2013).

"Apelação criminal - Sentença absolutória - Recurso do MP pela condenação Atentado violento ao pudor - Laudo de exame de corpo de delito que não descreve nenhuma lesão - Versão do apelante corroborada pelas testemunhas, inclusive pela avó e tia da vítima - Inexistência de testemunhas presencias do fato - Palavras da vítima que não encontram amparo nas provas produzidas Princípio basilar do processo penal - Busca da verdade real - Não comprovadas satisfatoriamente a autoria delitiva imputada ao acusado, de rigor a prolação de um decreto absolutório, por insuficiência de provas, aplicandose o princípio do in dubio pro reo Apelo ministerial não provido mantendose a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos." (TJ/SP, AP. 0048204-45.2005.8.26.0602, 16ª Câmara de Direito Criminal, Des. Borges Pereira, DJ. 15/03/2011).

E mais:

Apelação - Tráfico e associação para o tráfico - Sentença absolutória - Recurso ministerial - Improvimento - Fragilidade do conjunto probatório - Depoimentos dos guardas civis municipais insuficientes - Diversas contradições e situações desencontradas - Depoimentos dos guardas rechaçados pelos depoimentos dos acusados e das testemunhas defensivas, que restaram firmes e coerentes - Negativas apresentadas pelos acusados não ilididas por qualquer prova trazida aos autos sob o crivo do contraditório - Indícios de autoria insuficientes a embasar a condenação - Obediência ao princípio do 'in dubio pro reo' - Absolvição mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 00013633020188260248 SP 0001363-30.2018.8.26.0248, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 11/07/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2019)

Dessa forma, havendo a presença de razoável dúvida quanto à veracidade e dinâmica dos fatos imputados ao acusado, não há como se sustentar uma condenação por tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido já foi decidido nos autos da apelação n. 00950.485.3/6-0000-000, da 13ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pelo eminente Des. LOPES DA SILVA, e que se vê publicado in Lex 320/899, como se vê do seguinte destaque: "Não se nega, evidentemente, validade à palavra dos policiais. Sempre prestigiada pela jurisprudência, especialmente nos crimes de que tratam estes autos, de regra é suficiente para embasar um decreto condenatório. Nem por isso, entretanto, se lhe pode conferir infalibilidade que não lhe é própria. Assim, se a palavra dos policiais, por influência de alguma causa, não

exprime a certeza que dela se requer, revelando, antes, um estado de mera probabilidade, quando não de simples possibilidade ou de opinião a respeito do afirmado, não se lhe pode dar crédito suficiente e deve, como qualquer outro elemento de prova, ser afastado do conjunto probante, especialmente quando, como no caso, vem confrontada pela retratação judicial da única testemunha que a acompanhou a ação policial".

Sobre a matéria:

Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP

TÓXICO - Crime de tráfico - Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à posse ou propriedade da droga apreendida - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Dúvida remanescente que autoriza o decreto absolutório - Recurso defensivo provido e improvido recurso do Ministério Público - (voto n. 10.799). Apelação nº 3.953-80.2008.8.26.0619 (990.10.399.739-5), da Comarca de Taquaritinga, sendo apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São PauloO julgamento teve a participação dos Desembargadores ALMEIDA TOLEDO (Presidente) e PEDRO MENIN. São Paulo, 18 de janeiro de 2011. NEWTON NEVES RELATOR VOTO Nº 10.799

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS.APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Número do processo: 70042694125 Relator: Nereu José Giacomolli. O fato de ser policial, em princípio, não desnatura o depoimento na qualidade de testemunha. Precedentes do STF. A valoração, porém, dos depoimentos prestados por policiais, segue a mesma regra das demais provas produzidas sob o manto do contraditório judicial, impondo-se a sua comparação com o restante do contexto probatório. Para tanto, deve a autoridade policial, no momento do flagrante ou da abordagem, reunir todos os elementos indiciários que servirem para o esclarecimento do caso, identificando e inquirindo as testemunhas presenciais, de modo a permitir a formação do convencimento judicial futuro de modo mais exato. Hipótese dos autos em que, embora vários vizinhos tenham presenciado a abordagem policial, nenhum foi identificado e inquirido, restando a prova formada por depoimentos antagônicos de apenas um policial e do acusado. Dubiedade da prova que deve ser resolvida em favor do acusado. Princípio do in dubio pro reo. Veredicto condenatório reformado. Absolvição decretada. RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CRIME Nº 70.042.694.125 TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL - COMARCA DE PASSO FUNDO - ADRIANO TEIXEIRA DE SOUZA - APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO - APELADO.

Logo, muito frágil a prova testemunhal.

Saliente-se, ainda, que os agentes públicos trouxeram relatos incapazes de convencer que visualizaram alguma conduta do acusado que pudesse ensejar seu envolvimento no tráfico de drogas. Também inexistem nos autos quaisquer informações seguras de que ele seria traficante. Sequer havia denúncia anônima indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Não havendo denúncia anônima concreta, apreensão de dinheiro ou qualquer outro objeto relacionado ao tráfico, como ainda, não sendo ele surpreendido em situação de venda, não há como sustentar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito.

Não é possível condenar alguém com base apenas numa dedução, ou num mero juízo de probabilidade, assim como não é possível segregar uma pessoa por fundamento apenas na suposição de que a droga com ele localizada, repise-se, dezoito pinos de cocaína, estivesse destinada ao comércio ilícito, sobretudo considerando-se a gravidade da pena prevista e o rigor da lei no que se refere à sua execução. Ora, a quantidade da droga em poder do acusado, por si só, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, haja vista que é possível o consumo dessa quantidade por um dependente.

Portanto, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão que mais o beneficie. A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse

com a finalidade de uso próprio.

Sobre o tema:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. Recurso ministerial visando à condenação do apelado pelo delito de tráfico - IMPOSSIBILIDADE. Ausência de provas seguras de traficância. Restou provado nos autos que o dinheiro apreendido era produto de empréstimo. Policiais que confirmaram ser o apelado usuário de entorpecentes. Decisão de desclassificação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 36908420098260531 SP 0003690-84.2009.8.26.0531, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/11/2012).

PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. Apelo da Acusação para condenar o réu por tráfico de drogas, sem a concessão do redutor legal e com imposição do regime inicial fechado. Descabimento. Adequação do acervo de provas à desclassificação. A decisão de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas mostrou-se apropriada, diante da não uniformidade dos depoimentos dos policiais que o autuaram, bem como por estar na posse de pouca quantidade de droga, o que por si só não justificaria o "tráfico", e por se encontrar caminhando, quando abordada, em local que não se destinava ao hediondo comércio. Negado provimento. (TJ-SP - APL: 00010673220148260447 SP 0001067-32.2014.8.26.0447, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 25/05/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2017).

Tráfico de drogas - Confissão a propósito da posse para uso próprio - Apreensão de porções de cocaína em número compatível com o consumo - Prova oral pouco esclarecedora a propósito do tráfico - Acusado surpreendido em frente à sua casa - Dúvida razoável - Desclassificação para o art. 28, da Lei de Tóxicos - Cabimento - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00011358720158260530 SP 0001135-87.2015.8.26.0530, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/11/2018).

Nestes autos não existe nenhuma informação de que o acusado seja traficante, que comercializa drogas em algum local, ou ainda, sequer foi encontrado em situação que levasse a crer tal finalidade.

Diante deste contexto, incumbindo ao Ministério Público provar de maneira absoluta a traficância, o que não ocorreu, a desclassificação é medida que se impõe.

Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuir substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso próprio. O que existe nos autos são a autoria e a materialidade deste delito.

Prosseguindo, a autoria de Jovair restou devidamente comprovada, não obstante as escusas inconvincentes do acusado, que em seu interrogatório negou a prática da infração, argumentando que não possuía drogas consigo.

Ele sequer justificou a existência da droga encontrada em seu poder, em que pese não haver dúvidas sobre a apreensão do entorpecente pelos policiais. Não é crível que policiais inventem fatos ou "enxertem" a droga em desfavor de acusados, em especial quando nenhum vestígio a respeito existe nos autos.

A par disto, ele não comprovou o exercício de atividade lícita. Sequer soube explicar com segurança o local onde informou que prestava serviços de pedreiro. Desta forma, mostra-se sem origem o dinheiro localizado em seu poder e apreendido pelos policiais.

Ele também não explicou com coerência o motivo de ter tentado fugir dos policiais militares quando percebeu que seria realizada sua abordagem.

No mais, ele se escusou da imputação através de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais lhe imputar injustificadamente tal crime.

Se não bastasse a força de convencimento ínsita nos argumentos expostos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução.

Senão vejamos.

O Policial Militar Junio esclareceu que naquela ocasião realizou patrulhamento de rotina num conhecido ponto de tráfico de drogas e se deparou com o acusado. Contou que assim que notou a presença da viatura policial, Jovair tentou fugir do local. Contudo, foi perseguido e capturado. Realizada revista pessoal, com ele localizou algumas porções de cocaína, maconha e dinheiro. Logo em seguida, questionou o acusado sobre a situação e ele admitiu a propriedade da droga e sua intenção de vendê-la.

Suas palavras são ratificadas pelo PM Erick, que de forma séria e coerente asseverou a abordagem do acusado em conhecido ponto de tráfico de drogas, bem como atestou a apreensão do entorpecente em seu poder, além da admissão informal do acusado quanto à prática da infração.

Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade do agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, a forma como estava acondicionada em porções prontas para a venda, a diversidade de espécies, o local, o dinheiro sem justificativa da origem, as circunstâncias como foi surpreendido, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha o agente efetuado a venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor a venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, *verbi gratia*, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente à figura "trazer consigo", prevista no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento na pena base.

Os antecedentes criminais de Jovair recomendam exacerbação, conforme indica a certidão de fls. 61. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo as penas de Jovair em 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa no patamar mínimo legal. A pena de Luis será fixada em seu mínimo legal.

Na segunda etapa, certificada a reincidência de Jovair a fls. 62, não utilizada para efeitos de maus antecedentes, suas penas serão elevadas em 1/6, não havendo outras agravantes ou atenuantes a considerar ($6 \text{ anos} + 1/6 = 7 \text{ anos} / 600 \text{ dias} + 1/6 = 700 \text{ dias-multa}$).

Na etapa derradeira, deve ser reconhecida a causa especial de aumento denunciada, prevista no artigo 40, inciso III, uma vez que a prova é segura no sentido de que a infração foi praticada nas imediações de uma entidade religiosa (em frente à Igreja Assembleia de Deus e a 97 metros da Capela Santa Lúcia), conforme certificado no laudo anexo (fls. 166/168).

Logo, há proximidade entre os locais, verificando-se a influência e o potencial perigo que o comércio ilícito pode acarretar. Ressalte-se que para o reconhecimento da majorante não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente de fato atinja, diretamente, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc..., os frequentadores do local, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades.

Pretende a lei proteger tais locais, frequentados por grande quantidade de pessoas, algumas delas, em condições especiais. Portanto, o perigo à saúde pública é maior nestes locais, não exigindo a lei que o estabelecimento seja especialmente visado pelo agente.

Nesse sentido:

"Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da lei nº 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. (HC n. 407.487/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 15/12/2017).

"A prática do delito de tráfico de drogas nas proximidades de estabelecimentos de ensino enseja a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atingir os frequentadores desse local (STJ. 6ª Turma. AgRg no Resp. 1558551/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/09/2017 STJ; 6ª Turma. HC 359088/SP. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 04/10/2016).

Assim, as penas de Jovair serão acrescidas em 1/6 (7 anos + 1/6 = 8 anos e 02 meses/700 dias + 1/6 = 816 dias-multa).

O acusado é reincidente, razão pela qual não se amolda na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

O crime de tráfico foi equiparado, legalmente, aos hediondos, motivo pelo qual, em relação a ele, o condenado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade, mesmo porque a reincidência impede a substituição. Também compartilho do entendimento de que o crime de tráfico de drogas é a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias envolvidas, de modo que a concessão de regime menos gravoso ou mesmo de qualquer outro benefício, como a substituição da pena ou mesmo do sursis, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou mesmo reprovação da prática delitativa, gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, do Código Penal, além de verdadeira sensação de impunidade.

Por conta dos mesmos fundamentos, Jovair deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois é o que melhor se amolda para início do cumprimento da pena por crime tão grave e atroz contra a saúde pública. Qualquer outro regime prisional não se coaduna com o tráfico, diante de tantas mazelas que sabidamente a droga provoca.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ele não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel.

Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

No que se refere ao condenado Luis, em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de:

a) CONDENAR LUIS ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma do § 3º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução;

b) CONDENAR JOVAIR APARECIDO ROQUE, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Diante da desclassificação da imputação inicial de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, da lei especial, faculto ao condenado Luis o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o condenado Jovair na prisão em que ele se encontra.

Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 30 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA